

1501677-30.2020.8.26.0603

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: ADRIANO PINTO DE OLIVEIRA

Comarca: Birigui

Foro: Foro de Birigui

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 21/01/2022

... de precisão, o que só vem reforçar que ali se praticava o tráfico, haja vista que, como é cediço, balanças desse tipo são utilizadas para quantificar as porções que serão vendidas.

Além da balança, foram apreendidos um facão e rolo de plástico filme, o que só vem reforçar que ali se praticava o tráfico.

Nunca é demais lembrar que é desnecessária a prova de ato de comércio, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Birigui

Foro de Birigui

1ª Vara Criminal

Rua Faustino Segura nº 214, Birigui-SP - cep 16200-370

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1501677-30.2020.8.26.0603 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501677-30.2020.8.26.0603

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2291507/2020 - 01º D.P. BIRIGUI, 14830744 - 01º D.P. BIRIGUI, 1288/20/231 - 01º D.P. BIRIGUI, 2291507 - 01º D.P.

BIRIGUI

Autor:

Justiça Pública

Réu:

AGATHA EMELY SANTOS PIRES e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ADRIANO PINTO DE OLIVEIRA

S E N T E N Ç A

Processo nº. 1501677-30.2020.8.26.0603 (Controle nº 1996/20).

VISTOS.

AGATHA EMELY SANTOS PIRES, presa em flagrante delito, e LEONARDO POIATE DE CARVALHO, qualificados nos autos, foram denunciados e viram-se processados como incursos no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06 c.c. o artigo 29, caput, do Código Penal, porque, no dia 23 de novembro de 2020, por volta das 11h30min, à

Avenida Joaquim Ciciliati, 3259, Fundos, Jardim Sumaré, nesta cidade e comarca de Birigui, AGATHA, guardava 11,278 kg (onze quilos, duzentos e setenta e oito gramas) de maconha, distribuídos em 11 (onze) tabletes e 11 (onze) porções, substâncias entorpecentes que determinam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme laudos de fls. 25 e 89/91.

Consta, ainda, que, nas mesmas circunstâncias de tempo e espaço acima descritas, LEONARDO POIATE DE CARVALHO, concorreu para que Agatha Emely Santos Pires, guardasse 11,278 kg (onze quilos, duzentos e setenta e oito gramas) de maconha, distribuídos em 11 (onze) tabletes e 11 (onze) porções, substância entorpecente que determina dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, conforme laudo de fls. 25 e 89/91.

Oferecida a denúncia, os réus foram notificados (fls. 142 e 145) e apresentaram defesas escritas às fls. 114/121 e 149/150, sobrevindo o recebimento da denúncia em 08 de junho de 2021 (fls. 205/206).

Na instrução, foram colhidos os depoimentos de 02 (duas) testemunhas arroladas pela acusação, 03 (três) testemunhas arroladas pela defesa da ré Agatha e 05 (cinco) testemunhas do réu Leonardo, sobrevindo, ao final, os interrogatórios dos réus (fls. 336/337).

Em alegações finais, o Ministério Público pleiteou a parcial procedência da ação, absolvendo-se o réu Leonardo e condenado a acusada Agatha, nos exatos termos da denúncia (fls. 346/353).

A defesa do réu Leonardo pediu a sua absolvição, reiterando os argumentos expostos pelo Ministério Público em suas alegações finais (fl. 355).

Por sua vez, a defesa da ré Agatha, requereu, primeiramente, a revogação da prisão preventiva e deferimento da prisão domiciliar. Alegou que os policiais invadiram o domicílio da acusada, sem autorização legal, e que sofreu pressão psicológica para guardar a droga (coação moral irresistível). Pleiteou, por fim, a fixação da pena no mínimo legal, absorção do crime de associação, reconhecimento da confissão e aplicação da diminuição da pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/2006 (fls. 358/387).

É o relatório.

Decido.

Trata-se de ação penal pública incondicionada que se destina a apurar a responsabilidade dos denunciados pela prática de condutas que, em tese, estariam a configurar o delito de tráfico ilícito de drogas (art. 33, caput, da Lei nº. 11.343/06).

A ação penal é procedente.

Ao término da instrução criminal, e após um atento exame das provas existentes nos autos, não há como se deixar de reconhecer que a materialidade e a autoria deste crime narrado na denúncia ficaram satisfatoriamente comprovadas.

Nesse sentido, temos: o auto de prisão em flagrante (fl. 01); a nota de culpa (fl. 05); o boletim de ocorrência (fls. 10/12); o auto de apreensão e exibição (fls. 13/14); o laudo de constatação prévia (fl. 25); o relatório policial (fl. 93); o laudo pericial (fls. 89/91); os depoimentos das testemunhas e as indigestas e contraditórias negativas trazidas pelos acusados, em ambas as fases da persecução penal.

A ré Agatha, na delegacia, disse que conhece Leonardo e ele pediu se podia deixar “um negócio” na sua casa, fornecendo a chave de casa para que ele deixasse lá. Quando Leonardo foi até sua residência, não estava em casa e não chegou a ver o que ele havia guardado. No dia dos fatos, Leonardo ligou e falou que havia guardado maconha e iria buscar mais tarde. Estava no seu trabalho, quando policiais foram até o local perguntando sobre drogas na sua casa. Autorizou a entrada dos policiais. Disse que tinha conhecimento que Leonardo “mexia com drogas” (fl. 04). Em juízo, alterou a versão apresentada na fase policial. Confirmou que guardava drogas para um terceiro, porém, disse que era para uma pessoa chamada “Bruno”. Afirmou que Bruno pediu para deixar um pacote na sua casa, mas não sabia do que se tratava. Negou ter dado a versão dizendo que foi o Leonardo e não conhece o réu Leonardo (fls. 336/337).

Como se vê, a ré confessou a autoria dos crimes e delatou Leonardo na fase policial, mas, em juízo, alterou parcialmente a versão dos fatos, dizendo que quem deixou o entorpecente foi uma pessoa chamada Bruno.

Importante, também, observar que, na defesa prévia apresentada pela ré, especificamente às fls. 116/117 e 127/128 (prints de conversas em aplicativos de celular), há confirmação de que Agatha e Leonardo se conheciam.

Assim, a prova oral e documental produzida é robusta e só vem corroborando a confissão extrajudicial da acusada, caindo em descrédito a parcial retratação judicial por ela oferecida. É que a simples retratação em juízo, sem ressonância nos autos, não invalida confissão e delação feita perante a autoridade policial. Ademais, Agatha, ao apontar outra pessoa em juízo, visando inocentar o corréu Leonardo, não trouxe sequer o nome e endereço completo desse outro indivíduo, o que poderia levar à absolvição de Leonardo, tratando-se, na verdade, de alegação desprovida de elemento probatório, com a nítida intenção de afastar a responsabilidade do traficante que deixou a droga em sua casa.

Por sua vez, o corréu Leonardo, na delegacia e em juízo, disse que conhece Agatha, porém, nunca frequentou a casa dela. Negou ser proprietário da droga encontrada na casa de Agatha, e que não é traficante, apenas usuário (fls. 92 e 336/337).

Contudo, a negativa apresentada pelo acusado Leonardo está totalmente contrária às provas coligidas nos autos e isolada de todo o conjunto probatório, tendo sido contrariada por provas que apresentaram grau de idoneidade bem mais elevado, não passando de mero expediente utilizado na tentativa de se furtar da responsabilização penal por conduta efetivamente praticada.

Com efeito, a testemunha de acusação Daniel Aurelio de Freitas Lopes Zagatto, policial militar, ouvido em ambas as fases, relatou que estava em patrulhamento, quando uma pessoa informou que viu o acusado Leonardo deixar um saco plástico preto, com grande quantidade de maconha, na casa da ré Agatha. Dirigiu-se até a residência de Agatha e, ao chegar perto da porta da casa de Agatha sentiu forte odor de maconha. A acusada estava trabalhando e, cientificada confirmou que tinha aproximadamente 10 kg de drogas na sua casa. Agatha abriu a porta da casa e, na cozinha, encontrou um saco de lixo preto com onze tabletes de maconha e sobre a geladeira onze porções já embaladas para venda, balança de precisão e plástico filme. No lixo, localizou plástico adesivo marrom, comumente utilizado pelos fornecedores para embalar a maconha. Indagada, Agatha confirmou que guardava a droga para Leonardo Poiate de Carvalho, e que há diversas denúncias contra ele (fls. 02 e 336/337).

No mesmo sentido, o depoimento do policial militar Tiago da Silva Clemente, ouvido apenas na delegacia (fl. 03).

Os relatos dos policiais evidenciam, portanto, que os réus Agatha e Leonardo incidiram na prática do crime de tráfico ilícito de entorpecente. Lembre-se de que ambos os policiais ouviram de Agatha a confissão e a sua delação em face do corréu Leonardo. Os policiais ainda confirmaram que a acusada autorizou a entrada deles no imóvel.

Quanto à delação de Agatha em face de Leonardo, sabe-se que as declarações do corréu de um delito têm valor quando, confessando a parte que teve no fato criminoso, menciona também os que nele cooperaram como autores, especificando o modo em que consistiu essa assistência ao delito. Em outros termos, a delação de corréu que também assume sua responsabilidade na prática delitiva é válida como prova de participação do agente.

Desta forma, a delação da corré Agatha (em face do réu Leonardo), corroborando as provas jurisdicionalizadas, é idônea para evidenciar a participação do acusado Leonardo no crime ora apurado.

Anoto que o valor do depoimento testemunhal de servidores policiais, especialmente quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório, reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal.

Tal depoimento somente não terá valor quando se evidenciar o interesse do servidor na investigação penal, e quando suas declarações não encontrarem suporte em outros elementos probatórios idôneos.

Importante salientar que não existe qualquer circunstância que justificasse o interesse dos policiais em prejudicarem os acusados, ou em imputar falsamente a eles a prática de conduta definida como crime, sobretudo porque eles não apontaram nada que justificasse essa circunstância.

De outra parte, a alegação da defesa de invasão de domicílio, fica rejeitada. Pelo que se relatou na denúncia, os policiais militares receberam denúncia de que a ré estaria guardando entorpecentes para terceiros, razão pela qual se dirigiram até a residência da ré, no intuito de encontrarem as drogas, logo, houve situação que ensejava o estado de flagrância, justificador da entrada dos policiais. Evidente, portanto, que houve situação que ensejava o estado de flagrância, justificador da entrada dos policiais, sendo dispensável qualquer ordem judicial.

Ademais, embora a casa seja o asilo inviolável do indivíduo, não pode ser transformada em garantia de impunidade de crimes que em seu interior se praticam. Assim, em se tratando de flagrante delito, não é necessário mandado de busca e apreensão domiciliar, pois o próprio texto constitucional admite que se penetre na casa mesmo à noite, e sem o consentimento do morador, no caso de flagrante delito, como foi o ora tratado.

Como se não bastasse, é cediço que, em se tratando de crime permanente, é dispensável qualquer exibição de mandado e também a presença de civis no local, até porque se sabe que, no mundo do tráfico, é comum as testemunhas não aparecerem para depor e são raras as pessoas que prestam depoimentos em juízo, tudo por receio de represálias e ameaças por parte dos traficantes. Desprezar, como regra, a ação dos policiais em caso como o dos autos, seria fechar os olhos para a nossa realidade, o que seria inadmissível.

Por fim, como já mencionado acima, há notícias trazidas pelos policiais de que tanto a ré Agatha, quanto a testemunha Priscila, permitiram a entrada deles na residência, o que demonstra de vez a desnecessidade de mandado de busca domiciliar. A testemunha Priscila dos Santos Rodrigues, ouvida em juízo, disse que os policiais adentraram na sua casa e, após revista, perguntaram da ré Agatha. Informou que ela morava no fundo da residência e eles foram até lá, entraram pelo telhado, mas não viu se encontraram entorpecentes. Afirmou que não conhece Leonardo (fls. 336/337). As testemunhas de defesa de ambos os réus Roberto Jabrayan, Marcia Melo Santos da Costa, Mariella Cristina Milani, Estevão Rodrigues de Oliveira, não presenciaram os fatos, limitando-se a tecer comentários sobre os acusados (fls. 336/337).

Os depoimentos dessas testemunhas não têm o condão de afastar os depoimentos dos policiais e infirmar o restante do conjunto probatório.

As testemunhas arroladas pelo réu Leonardo, Mafalda Borges Poiati, Aparecida Poiati, Fabio Poiati e Michelle Pederiva de Brito, ouvidas em juízo, mãe e tios do réu, disseram que, no dia dos fatos, ele estava na casa da sua mãe, em um churrasco (fls. 336/337).

Como se viu, essas testemunhas afirmaram que o réu não saiu de casa durante o dia, mas nenhuma delas disse que, durante a noite (período em que teria deixado a droga na casa de Agatha), elas estavam com o réu.

Ademais, ainda que assim não fosse, o certo é que esses depoimentos dessas testemunhas, se cotejados com os demais elementos de prova, não poderiam merecer a mesma credibilidade, uma vez que, por se tratar de parentes do réu, prestaram depoimentos sem compromisso legal.

No que se refere ao entorpecente, a perícia apontou que consiste realmente em "maconha" (exame químico-toxicológico de fls. 89/91).

De outra parte, a grande quantidade de entorpecente apreendido, ou seja, 11,278 quilogramas de maconha, as circunstâncias da abordagem da ré (denúncia de tráfico de drogas); a forma de acondicionamento da droga (parte distribuída em porções, pronta para comércio, e outra ainda em tabletes), a apreensão de uma balança de precisão, facão, rolo de plástico filme; a confissão da ré Agatha, estão a caracterizar a traficância.

Não se pode olvidar que foi apreendida uma balança de precisão, o que só vem reforçar que ali se praticava o tráfico, haja vista que, como é cediço, balanças

desse tipo são utilizadas para quantificar as porções que serão vendidas. Além da balança, foram apreendidos um facão e rolo de plástico filme, o que só vem reforçar que ali se praticava o tráfico. Nunca é demais lembrar que é desnecessária a prova de ato de comércio, bastando que o agente guarde a droga para essa destinação, ainda que futura, na medida em que a consumação não exige qualquer resultado. No caso, os réus foram denunciados por guardarem os entorpecentes (Agatha) e por concorrer que o corréu guardasse (Leonardo) as drogas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Não se pode olvidar que o tipo penal do artigo 33 da Lei nº. 11.343/06 é chamado de tipo misto alternativo, possuindo vários núcleos, dentre eles, guardar entorpecente, conduta essa efetivamente praticada pelos acusados, mas que caracterizam crime único.

Assim, além da robusta prova acima analisada, há indícios mais que suficientes para a prolação de decreto condenatório. Aliás, neste ponto, tratando-se de delito, na maioria das vezes, praticado às escondidas, não se pode abrir mão dos indícios para o estabelecimento da verdade real. E a definição de indício vem estabelecida no próprio Código de Processo Penal, no artigo 239. Com isso, constata-se que o juiz formará a sua convicção na livre apreciação da prova, e, diante do nosso sistema processual, o indício é o fato provado que, por sua ligação íntima com o fato probando, autoriza a concluir algo sobre este, até porque os indícios estão inscritos no título da prova, e, assim, a autoria do delito, pelo sistema do livre convencimento, pode ser demonstrada, validamente, pela força probante dos indícios. Portanto, a prova coletada nos autos é substanciosa e convincente, ficando evidente a autoria do crime por parte dos réus, no crime ora apurado. Lembre-se que, no caso, não se exige o chamado "dolo específico", mas apenas o dolo genérico, restando evidente que Agatha guardava a droga descrita na denúncia para entrega a consumo de terceiros e que Leonardo concorreu para tanto.

Sendo assim, não resta dúvida de que no dia, horário e local indicados na denúncia, a acusada Agatha guardava 11,278 quilogramas de maconha, substâncias entorpecentes, que determinam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, para fins de entrega a consumo de terceiros; e o corréu Leonardo concorreu para tanto. A conduta dos réus encontra tipicidade na exata correspondência com o delito definido no artigo 33, caput, da Lei nº. 11.343/06, nos moldes do artigo 29, do Código Penal.

Inexistem causas que afastem a ilicitude da conduta, exclua a culpabilidade dos denunciados ou extingam a punibilidade. Neste ponto, embora o acusado Leonardo, em seu interrogatório, tenha alegado que é usuário de drogas, tais alegações não restaram comprovadas, até porque a defesa não juntou quaisquer documentos, não requereu qualquer exame de dependência químico-toxicológico ou de insanidade mental.

Ressalto que, mesmo que se demonstrasse que o réu fosse usuário de drogas, isso, por si só, não lhe impediria de exercer a traficância. Muito pelo contrário, há grande afinidade entre uma e outra condutas. Se o réu é viciado há um bom tempo, isso facilita o ingresso no submundo do crime, principalmente no mercado de substâncias tóxicas.

Diante desse quadro, a condição de ser o agente usuário não exclui a possibilidade de ser condenado como traficante, porque são situações que não se excluem. Neste ponto, não prospera a alegação de que a ré Agatha teria agido mediante coação moral irresistível. Como se sabe, essa figura somente está presente quando a coação não poderia ser vencida ou superada pelo agente no caso concreto, o que não é caso dos autos. Frise-se, a ré não arrolou qualquer testemunha que comprovasse tal fato, tratando-se de alegação vazia trazida pela defesa, nas alegações finais, sem qualquer fundamento, no simples intuito de afastar sua responsabilidade penal. Reconheço, pois, a ocorrência do delito e passo a aplicar as penas.

Penas.

Os réus não registram maus antecedentes, no entanto, nesta fase da aplicação da pena, deve ser levado em conta que a introdução da considerável quantidade de droga no mercado, se fosse alcançada, traria efeitos altamente lesivos à sociedade. Evidente, assim, a necessidade de um maior rigor na fixação da pena-base, em patamar acima do mínimo legal, lembrando que seria absolutamente desprovido de razoabilidade apená-lo com a sanção base mínima, tratando-o igualmente, por exemplo, a quem fosse preso traficando algumas gramas daqueles entorpecentes. Essa é a posição de nossos Tribunais:

“Na avaliação das circunstâncias legais para a fixação da pena, em se tratando de tráfico de entorpecentes, devem influir decisivamente a espécie e a quantidade da droga. O tipo de entorpecente é dado que indica o grau de nocividade para a saúde pública, correlato ao indicador das conseqüências do crime; a quantidade, quase sempre, aponta para o grau de envolvimento do infrator com o odioso comércio, indicando a medida de sua personalidade perigosa e voltada para a prática criminosa” (STJ, HC 13.231-MS, 5ª T., j. 22.08.2000, rel. Min. José Arnaldo da Fonseca, DJU 09.10.2000 – RT 786/599).

“Nos casos de tráfico de entorpecente, a fixação da pena obedecerá aos critérios do art. 59 do CP entre eles os motivos, as circunstância e conseqüências do crime, razão pela qual se admite a fixação de pena-base acima do mínimo legal, se houve apreensão de grande quantidade de droga” (STJ, HC 11.235-SP, 5ª T., j. 16.03.2000, rel. Min. José Arnaldo da Fonseca, DJU 17.04.2000, RT 783/594).

“Admissível, em tema de comércio clandestino de entorpecente, é a maior severidade na repreensão penal em face da natureza mais nociva ou da maior quantidade de substância tóxica apreendida” (TACRIM-SP-AC-Rel. Geraldo Pinheiro – JUTACRIM 44/293).

“A alta nocividade da cocaína está a exigir especial rigor no combate a seu tráfico, impondo-se, em conseqüência, a aplicação aos traficantes de reprimendas penais de severidade correspondente ao elevado risco que a nefanda mercancia acarreta à saúde pública” (TJRS – AC – 687055624 – Rel. Alberto de Moraes Lacerda – RJTJRS 130/154)

PENA – Agravantes – Tráfico de entorpecentes – Associação – Hipótese em que, se a Justiça Pública houvesse apelado, caberia modificação no decreto condenatório, pois a grande quantidade de entorpecente apreendida justificaria plenamente a aplicação da pena-base acima do mínimo legal, além de que o “modus operandi” do casal criminoso, demonstra organização que merecia maior rigor punitivo; todavia, como não é possível “reformatio in pejus”, a pena cominada na r. sentença deve prevalecer – Preliminar rejeitada, recurso parcialmente provido. (Apelação Criminal n. 1.044.309-3/5 – São Paulo – 6ª Câmara Criminal – Relator: Marco Antonio – 23.8.2007 – V.U. – Voto n. 6.277)

Portanto, levando em conta o dado elencado, no aspecto acima relatado (quantidade da droga), fixo a pena-base acima do mínimo legal em 1/2 (metade), resultando em 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, e pagamento de 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa, no valor mínimo unitário (art. 43, caput, da Lei nº 11.343/06).

Na segunda fase, com relação à ré Agatha, reconheço a atenuante da confissão espontânea e reduzo a pena em 1/6 (um sexto), resultando em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão, e pagamento de 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa.

Com relação ao réu Leonardo, não há agravantes e atenuantes a serem reconhecidas. Na terceira fase, não é caso de incidência da causa de diminuição de pena do artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, porque restou demonstrado, por todos os elementos

acima descritos, bem como pela apreensão de grande quantidade de droga (nada menos do que 11,278 quilogramas de entorpecentes), que os acusados se dedicavam à narcotraficância em escala expressiva, de modo que é forçoso reconhecer que se dedicava a atividade criminosa, fazendo do tráfico o seu meio de vida. Neste sentido, já se decidiu:

“ Sem incidência , porém, na última fase da dosagem, de retroativa redutora, por conta do artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06, visto que, pese a primariedade e bons antecedentes, concretamente, a forma de embalagem da droga apreendida (cerca de sessenta e cinco invólucros), sua natureza (crack) e forma de ação desenvolvida - para fim de venda a indeterminado número de pessoas - antes de caracterizar eventual pequeno tráfico, traz indicações de fazer do fato modo de vida, exercício de atividade criminosa.”

Em outros termos, a quantidade expressiva de entorpecente, inversamente ao princípio da insignificância, poderia causar consequências gravíssimas a um número imenso de pessoas, bem como denota periculosidade acentuada por parte dos acusados, já que realizavam o tráfico em escala considerável, o que deve ser diferenciado do pequeno traficante, sob pena de violação do primado da igualdade, razão pela qual não faz jus à redução em questão.

Torno definitiva a pena em 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, e pagamento de 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa, no valor mínimo unitário (art. 43, caput, da Lei nº 11.343/06), para o réu Leonardo, e 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão, e pagamento de 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa, para a ré Agatha.

Diante da gravidade da conduta, mesmo levando-se em conta a detração penal disposta na Lei nº 12.736/12 (art. 2º, que acrescentou o § 2º ao art. 387 do CPP), a pena deve ser cumprida no regime inicial fechado, obrigatoriamente, pois se trata de crime equiparado a hediondo, conforme estatuído no art. 2º, § 1º, da Lei nº 8.072/90.

Ademais, infere-se inviável, de igual sorte, a alteração do regime prisional, na hipótese, com esteio no lapso que perdurou a prisão cautelar, porque não se tem notícia a respeito da real situação carcerária dos acusados, isto é, se não registra outras condenações ou prisões processuais, nem quanto ao seu comportamento e conduta no cárcere, a revelar não existirem elementos seguros para a correta análise, nesta seara e de pronto, quanto a eventual direito à detração penal, emergindo mais adequado que o juízo da execução se manifeste por primeiro, à míngua de informações concretas.

A acusada Agatha deverá continuar a responder presa por este processo, pois assim permaneceu durante a instrução e ainda estão presentes os requisitos da custódia cautelar, como se verá doravante.

O réu Leonardo poderá continuar a responder por este processo solto, pois assim permaneceu durante a instrução, não estando presentes os requisitos da custódia cautelar.

Fixo cada dia-multa no valor mínimo unitário legal, diante a ausência de informações seguras sobre a capacidade econômica dos réus.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal para:

- 1) CONDENAR AGATHA EMELY SANTOS PIRES, qualificado nos autos, ao cumprimento das penas de 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão, em regime inicial fechado (art. 2º, §1º, da Lei nº 8.072/90, com a redação da Lei nº 11.464/07) e pagamento de 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa, no valor mínimo unitário (art. 43, caput, da Lei nº 11.343/06), por infração ao artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06;
- 2) CONDENAR LEONARDO POIATE DE CARVALHO, qualificado nos autos, ao cumprimento das penas de 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado (art. 2º, §1º, da Lei nº 8.072/90, com a redação da Lei nº 11.464/07) e pagamento de 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa, no valor mínimo unitário (art. 43, caput, da Lei nº 11.343/06), por infração ao artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, nos moldes do artigo 29, do Código Penal.

Consigno que a acusada Agatha ficou presa cautelarmente desde 23/11/2020 até a

presente data, período sobre o qual fica reconhecida a detração penal, para fins de cumprimento do restante da pena, nos termos do que dispõe o artigo 1º da Lei nº 12.736/12.

Deve, no entanto, a Serventia, ao expedir a Carta de Guia, atentar para se consignar a condenação total constante do dispositivo acima, com as observações consignadas no parágrafo anterior (detração penal).

Deixo de substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, por entender incabível tal providência.

Não obstante o julgamento do Habeas Corpus n. 97.256, pelo Supremo Tribunal Federal, no qual se entendeu por inconstitucional a vedação à substituição por penas restritivas de direitos para o crime de tráfico, por afronta ao princípio da individualização da pena, até então não se trata de decisão proferida com efeito erga omnes.

Foi editada a Resolução nº 5/2012, do Senado Federal, que, nos termos do artigo 52, inciso X, da Constituição Federal, suspendeu a execução de parte do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, que vedava de forma abstrata (sem análise do caso concreto) a conversão em penas restritivas de direito, declarada inconstitucional por decisão definitiva do Supremo em decisão no Habeas Corpus já mencionado acima.

Com a mencionada Resolução, não se pode mais afirmar que o efeito do julgamento daquele habeas corpus não é para todos. Entretanto, a intenção do Supremo Tribunal Federal, ao decidir desta forma, e o Senado Federal, ao editar a resolução, foi somente deixar à prudente análise do magistrado do caso concreto se o réu tem ou não direito a ter a pena privativa de liberdade substituída por restritiva de direitos, e não que essa substituição seja admitida em qualquer caso de tráfico de drogas, indistintamente. Pensar assim seria um contra-senso.

Confira, neste sentido, decisão proferida em Apelação Criminal que analisou sentença proferida por este juízo:

"... Inviável, nesse passo, a pretendida substituição carcerária por restritivas de direito, porque, embora o teor da recente Resolução nº. 5/2012 do Senado Federal, fundada na decisão do Supremo Tribunal Federal proferida nos autos do Habeas Corpus, nº. 97.256/RS - mencionado nas razões recursais -, em controle difuso de constitucionalidade, in casu, permanece impossível, data vênica, a substituição prevista no artigo 44 do Código Penal, ou mesmo a concessão de sursis, pois o crime de tráfico de entorpecentes revela a gravidade peculiar que desestabiliza a vida em sociedade e fere de morte a saúde pública, pois enquanto fomenta, simultânea e irremediavelmente - até as pedras estão cansadas de saber -, a violência, a destruição de lares e das famílias e a prática de n crimes, sobretudo para o fim de viabilizá-lo, tanto assim que, por força de norma constitucional, é assemelhado aos delitos hediondos, cuja pena deve ser cumprida no regime prisional inicial fechado, determinação esta que se mostra incompatível com a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos ou com a suspensão condicional da pena, de modo que não se consegue compreender ou avaliar, por mais que se esforce, qual seria a pena substitutiva ou as condições do sursis adequadas ao traficante, emergindo sintomático que - até o momento - jurista sério algum tenha ousado sugerir-las..." (TJ-SP, Apelação Criminal nº 0009435-15.2010.8.26.0077, 5ª Câmara Criminal, rel. Des. Juvenal Duarte, j. 19.04.2012).

Ainda no mesmo sentido, confira julgamento proferido em processo que tramitou por essa comarca de Birigui:

"Também não faz jus a apelante à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

A concessão da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos aos condenados a tráfico de drogas é incompatível com a gravidade e as circunstâncias em que o crime é cometido, não havendo qualquer tipo de violação ao princípio da individualização da pena.

Este entendimento deve prevalecer, notadamente ao se considerar a vedação expressa

trazida pelo artigo 44 da Lei de Drogas.

Com efeito, o benefício consistente na substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos tem por objetivo primordial o de possibilitar a ressocialização de indivíduos de baixa periculosidade, que praticaram delitos de pequeno grau de lesividade social.

Traficantes de substâncias entorpecentes, sejam de pequeno, médio ou grande porte, não tem o perfil de iniciar o cumprimento de sua pena que não mediante encarceramento. Mesmo o pequeno traficante merece uma punição severa. Basta que a venda de drogas seja realizada uma única vez, para que cause uma série de malefícios ao consumidor, as quais virão a repercutir a toda a coletividade.

Ressalta-se que uma das exigências previstas no artigo 44, inciso III, do Código Penal, para a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos é a de que os motivos e as circunstâncias indiquem como suficiente tal medida, para a repressão do agente da conduta delituosa.

Conforme já fundamentado, tal benefício não se coaduna com as graves consequências que a mercancia de substâncias entorpecentes causa, não só ao usuário, com uma rápida deterioração da sua saúde física e mental, mas também ao corpo social (desestrutura familiar, estímulo à prática de outros crimes, como homicídios, latrocínios, extorsões etc.).

Muito embora o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do "Habeas Corpus" nº 97256/RS, tenha expressão "vedada a conversão em penas restritivas de direitos", contida no § 4º, do artigo 33, da Lei 11343/06, é de se ressaltar que tal decisão não possui o erga omnis.

E mesmo a resolução nº 5 do Senado Federal, de 15 de fevereiro de 2012, que suspendeu a eficácia da referida expressão, não acarreta direito subjetivo do agente que praticou o grave delito do tráfico de entorpecentes a tal conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos.

Frise-se, ainda, que o artigo 44 da Lei de Drogas mantém tal vedação ao crime de tráfico de drogas, previsto no artigo 33, caput. Considerando que o § 4º é tão somente uma causa de diminuição do delito previsto no caput - e não um crime autônomo -, é possível concluir que a vedação a ele também se aplica.

Neste aspecto, ensina Guilherme de Souza Nucci que "(...) o fato de haver sido prevista uma causa de diminuição de pena para o traficante primário, de bons antecedentes, sem outras ligações criminosas, não afasta a tipificação da sua conduta como incursas no artigo 33, caput e § 1º, que são consideradas similares a infrações penais hediondas, como se pode observar pelas proibições enumeradas no artigo 44 da Lei 11343/06. Salienta-se, ademais, o cuidado legislativo em vedar a aplicação da substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, típica opção de política criminal para o tráfico ilícito de drogas. Não se pode criar uma nova infração penal, a partir da mera aplicação de causa de diminuição de pena. Por isso, o tráfico ilícito de drogas será sempre considerado equiparado a hediondo, ainda que comporte, por opção legislativa, pena mais branda, quando os requisitos do § 4º estiverem presentes" (in "Leis Penais e Processuais Penais Comentadas", 5ª ed., São Paulo, Revista dos Tribunais, 2010, p.372).

Desta forma, NEGOU PROVIMENTO ao recurso, mantendo, integralmente, a respeitável sentença de primeiro grau" (Apelação Criminal nº 0002364-20.2014.8.26.0077. Rel. Toloza Neto).

Não bastassem esses argumentos, anoto ainda que as penas fixadas para os réus ultrapassam quatro anos, o que afasta de vez a substituição das penas privativas de liberdade por restritivas de direitos.

A ré Agatha deverá continuar a responder presa por este processo, eis que sua prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva, conforme decisão proferida às fls. 42/43, a cujos fundamentos me reporto, como razão de decidir.

O pedido de prisão domiciliar fica indeferido, primeiro, porque praticou crime de tráfico de drogas no imóvel onde reside com a própria filha menor, situação esta que, por si só, impede a concessão de prisão domiciliar, consoante jurisprudência dos tribunais. Ademais, a quantidade de drogas apreendidas (mais de quilos de maconha) apontam a gravidade da situação, a periculosidade da ré e o risco da menor

em ficar com a mãe na residência.

A confirmar a necessidade da manutenção da prisão cautelar do réu, estão os dois Habeas Corpus impetrados em favor da acusada Agatha, no Tribunal de Justiça e no Supremo Tribunal Federal, que tiveram suas liminares indeferidas, e, ao final, suas ordens denegadas (fls. 79, 283/290, 291/301 e 391/395).

Recomende-se a ré Agatha na prisão em que se encontra, com fundamento nos artigos 59 da Lei nº 11.343/06, c.c. o § 4º do artigo 2º da Lei nº 8.072/90, acrescentado pela Lei nº 11.464/07.

O réu Leonardo poderá continuar a responder por este processo solto, pois assim permaneceu durante a instrução, não estando presentes os requisitos da custódia cautelar.

Por fim, em atenção ao disposto no artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, após 85 (oitenta e cinco) dias contados da publicação da sentença, tornem os autos conclusos para revisão da necessidade de manutenção ou não da decisão que manteve a prisão preventiva, mantendo-se os autos na fila "acompanhamento de prisão preventiva".

A incineração da droga já foi determinada e realizada às fls. 42/43, respectivamente, nada mais havendo a ser decidido a respeito.

Com fundamento nos artigos 91, inciso II, alínea "b", do Código Penal, e 63 da Lei nº. 11.343/06, decreto o perdimento, por serem instrumentos e produtos do tráfico de entorpecentes praticado pelo acusado, dos bens descritos nos autos de exibição e apreensão de fls. 13/14 (rolo de plástico filme, balança de precisão, faca).

Após o trânsito em julgado, comunique-se o "Senad" quanto ao perdimento supradeterminado, instruindo o ofício com cópias do auto de exibição e apreensão, da presente sentença e eventual Acórdão, bem como das certidões de trânsito em julgado para as partes.

Oficie-se à Delegacia de Polícia de origem, informando sobre a destruição dos bens, instruindo-se o ofício com as cópias.

Fixo cada dia-multa no valor mínimo unitário legal, diante a ausência de informações seguras sobre a capacidade econômica dos réus.

Com o trânsito em julgado da presente, oficie-se ao Cartório Eleitoral, nos termos do artigo 28 da Resolução nº 23.399/13 do TSE, instruindo o ofício com cópias da presente sentença e eventual Acórdão, bem como das certidões de trânsito em julgado para as partes.

Custas, na forma da lei.

P. R. I.

Birigui, 21 de janeiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA